

1007141-43.2022.8.26.0047
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Empréstimo consignado
Magistrado: ANDRE LUIZ DAMASCENO CASTRO LEITE
Comarca: Assis
Foro: Foro de Assis
Vara: 3ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 29/12/2022

... do débito e que não alegou que houve roubo, furto ou perda dos seus documentos, bem como não há sinais visíveis de fraude. Afirmou, por fim, que o valor do empréstimo foi depositado na conta corrente da parte autora e que a contratação preenche os requisitos legais de validade, atendendo todas finalidades e, por essas razões, requereu a improcedência dos pedidos formulados na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Assis
Foro de Assis
3ª Vara Cível
Rua Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis - SP - cep 19802-300
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1007141-43.2022.8.26.0047 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1007141-43.2022.8.26.0047
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado
Requerente:
Maria Dalvina Correa
Requerido:
BANCO CETELEM S.A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DAMASCENO CASTRO LEITE

Vistos.

MARIA DALVINA CORRÊA propôs "ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c restituição e indenização por danos morais" em face de BANCO CETELEM S/A, alegando, em síntese, que é beneficiária junto ao INSS e que tomou conhecimento de que em fevereiro de 2017 a ré passou a descontar indevidamente de seu benefício previdenciário parcelas mensais de R\$ 17,05, em decorrência do contrato de empréstimo consignado nº 5182264436617, no valor de R\$ 565,45. Afirmou, entretanto, que jamais solicitou tal empréstimo, tampouco assinou qualquer contrato junto ao banco requerido. Alegou, ainda, que não se recorda de ter recebido a referida quantia e, vendo-se desamparada, não viu alternativa diversa senão recorrer ao Poder Judiciário. Sustentou que os descontos foram indevidos e devem, portanto, ser restituídos em dobro. Ainda, que os descontos indevidos lhe causaram danos morais que devem ser indenizados. Por essas razões, requereu a declaração de inexistência do contrato ora impugnado, com a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo e, ao final, a declaração de

ilegalidade dos descontos, com a condenação do banco requerido à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, além da condenação ao pagamento a título de danos morais no importe sugerido de R\$ 15.000,00; e aos encargos de sucumbência.

A inicial veio acompanhada de procuração e demais documentos (fls. 12-19).

A decisão de fl. 20 concedeu à autora os benefícios da justiça gratuita e determinou a citação do réu.

Citado (fl. 21), o banco réu apresentou sua contestação às fls. 63-68, arguindo, preliminarmente, prescrição, visto que a contratação ocorreu em 02/02/2017, tendo a autora ajuizado a presente demanda somente em 13/08/2022, sendo evidente a prescrição do direito pleiteado pela parte autora.

No mérito, sustentou que a parte autora contratou efetivamente junto à ré, visto que há contrato assinado pela parte autora; que as assinaturas conferem com os documentos de identificação pessoal juntados na inicial; que no ato da contratação, houve a apresentação do documento de identificação original; que foram disponibilizados à parte autora os valores objeto do contrato informado. Aduziu, também, que na data 02/02/2017, a parte autora assinou contrato de empréstimo consignado de nº 51-822644366/17, com pagamento por consignação em folha, dividido em 72 parcelas de R\$ 17,05 e apresentou documento de identidade original para isso. Sustentou, além disso, que na data 08/02/2017, a parte autora recebeu, em sua conta corrente, por meio de uma Transferência Eletrônica Disponível (TED), o valor de R\$ 554,57. Narrou que, durante todo esse período, a parte autora não questionou os valores que lhe foram disponibilizados e ainda os utilizou, uma vez que este crédito se deu nos termos e formas indicados na contratação. Sustentou que, na data 13/08/2022, a parte autora ajuizou a presente ação judicial alegando não se lembrar que firmou o referido contrato. Afirmou que a autora não alegou que houve vício na relação contratual que justifique uma anulação do ato ou o não pagamento do débito e que não alegou que houve roubo, furto ou perda dos seus documentos, bem como não há sinais visíveis de fraude. Afirmou, por fim, que o valor do empréstimo foi depositado na conta corrente da parte autora e que a contratação preenche os requisitos legais de validade, atendendo todas finalidades e, por essas razões, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A contestação veio acompanhada de documentos (fls. 69-88).

Réplica às fls. 92-96, na qual a autora impugnou a assinatura constante no contrato. Sustentou que a assinatura no contrato encontra-se quase que ilegível e embaçada; que a assinatura foi colada no contrato, visto que esta foi alterada e, por essas razões, requereu a inversão do ônus da prova e a procedência da demanda. A decisão de fls. 97-98 afastou a prejudicial de prescrição e declarou o feito saneado. Ainda, atribuindo ao réu o ônus de demonstrar a contratação, determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

Pela petição de fl. 101, o banco réu pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento para depoimento pessoal da autora.

À fl. 102, a parte autora informou que não havia mais provas para apresentar nos autos, bem como reiterou o pedido de inversão do ônus da prova e o julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

Passo à fundamentação.

Inicialmente, indefiro o pedido de depoimento pessoal da parte autora formulado pelo banco réu.

No processo serão realizadas apenas as provas necessárias e úteis, sendo excluídas as demais que, no entendimento do juiz, se mostrarem inócuas para o deslinde do feito.

De fato, embora ao réu tenha sido atribuído o ônus de demonstrar a referida contratação, observo que a alegação da parte autora contida na inicial já é no sentido de não ter celebrado os contratos impugnados nesta demanda. Após o banco trazer aos autos os dados da contratação e o próprio contrato, em réplica, a parte autora volta a negar a celebração do contrato alegando falsidade da assinatura. Poderia o réu, por exemplo, para se desincumbir de seu ônus probatório, requerer a produção de prova pericial que pudesse demonstrar que foi a parte autora quem

firmou o contrato impugnado.

Assim, em abono ao princípio da razoável duração do processo, não se justifica a designação de audiência para oitiva de depoimento pessoal da parte que, já na petição inicial e na réplica, informou não ter celebrado o contrato.

Superada essa questão, verifico que o processo está em ordem e comporta julgamento imediato, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega a autora que não firmou com o requerido contrato de empréstimo consignado impugnado nos autos que deu azo aos descontos em seu benefício previdenciário.

Em sua defesa, o requerido afirma que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, não havendo qualquer vício na contratação, sendo a requerente beneficiada com o depósito do valor emprestado em sua conta corrente.

Conforme decisão de fl. 97-98, foi atribuído ao réu o ônus de demonstrar a efetiva contratação por parte da autora do empréstimo impugnado na inicial.

De fato, estabelece o artigo 429, do CPC, que: "Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento".

Assim, em se tratando de impugnação de autenticidade de documento, com imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do dispositivo citado.

A propósito, oportuno ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.846.649/MA, processo-paradigma do Tema n. 1061 Banco. Empréstimo Consignado. Ônus Prova. Falsidade Assinatura, firmou a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

No entanto, deste ônus o banco não se desincumbiu, pois tendo a oportunidade de indicar as provas que pretendia produzir, requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de depoimento pessoal da autora, prova que, conforme exposto acima, não se presta à demonstração da efetiva contratação, diante das negativas já apresentadas pela autora em sua inicial e réplica.

Nesse norte, considerando que a dúvida se resolve em prejuízo de quem tinha o ônus de demonstrar o fato controvertido e que tal ônus era do réu, entendo que se deve conferir veracidade às informações contidas na inicial e em réplica, isto é, de que a parte autora não contratou qualquer tipo de empréstimo consignado, bem como de que as assinaturas constantes do contrato em comento não emanaram de seu punho.

Além disso, vislumbro que as provas até então existentes nos autos não demonstram, de forma inequívoca, a contratação pela parte autora do empréstimo impugnado na inicial, já que existe a possibilidade de que terceiros tenham-se utilizado, fraudulentamente, de dados e cópias de documentos da parte autora, falsificando as assinaturas constantes das cédulas impugnadas.

Logo, não restou demonstrada a regular origem dos descontos previdenciários alegados na inicial.

Ocorre que a exigibilidade dos descontos em benefício previdenciário da autoar submete-se à existência de amparo negocial para tanto, sendo que a inação probatória do requerido importa na conclusão de que os descontos referidos na inicial são indevidos, realizados sem lastro em serviço efetivamente contratado. Diante disso, forçoso concluir pela nulidade da contratação impugnada nesta demanda e a consequente inexistência da dívida, diante da ausência dos requisitos legais, dentre eles, a vontade de contratar, pois presume-se que a assinatura contida no contrato pactuado não pertence à parte autora.

Face à declaração de nulidade, o réu deverá se abster de efetuar novas cobranças com embasamento no negócio inexistente, no que se inclui eventuais negativações, devendo restituir todos os valores descontados do benefício previdenciário da autora por força dos fatos descritos na inicial, devidamente corrigidos e atualizados.

Por outro lado, também deverá a demandante devolver ao banco réu os valores do empréstimo, com correção monetária pelos índices do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir de sua disponibilização. Isso porque restou comprovado que o valor

do empréstimo foi disponibilizado à autora, no valor de R\$ 554,57 (fl. 74). Assim, como consequência da declaração de nulidade do contrato, as partes devem retornar ao estado anterior, nos termos do art. 182, do Código Civil, devendo a autora, portanto, devolver o valor do empréstimo. Revendo posicionamento anteriormente firmado quanto à forma de devolução em demandas dessa natureza, passo a adotar o entendimento de que a restituição dos valores indevidamente descontados deve se dar em dobro, independentemente da natureza do ato volitivo do fornecedor dos serviços no momento da contratação. Em outras palavras, é desnecessária a comprovação da má-fé, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva. Na realidade, há de se convir que impor ao consumidor a prova da existência de má-fé, como condição permissiva da devolução em dobro, é algo quase impossível, por ser ele a parte mais vulnerável da relação jurídica. Aliás, essa é a literalidade do art. 42 do CDC:

"Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Dito isso, cabe ao fornecedor de serviços a comprovação de erro justificável a fim de ser afastada a forma dobrada, ônus do qual o réu não se desincumbiu (art. 373, II do CPC).

Além disso, a matéria foi decidida, recentemente, em EA REsp nº 676.608/RS, onde por unanimidade pacificou a controvérsia sobre a possibilidade da restituição na forma dobrada:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRO CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO." (EAREsp 676608 / RS, Relator(a)Ministro OG FERNANDES, Órgão Julgador: CE - CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação: DJe 30/03/2021) (g.n).

Reiterando-se, a má-fé não é requisito para determinar a restituição de valores em dobro.

Ora, considerando que foi a própria instituição financeira ré, através de seu correspondente bancário (preposto dela, portanto) que colheu a documentação e as assinaturas na cédula de crédito bancário, não há como afastar a conclusão de que agiu com negligência ao não verificar que a pessoa contratante não se tratava do autora.

Assim, inexistiu "engano justificável", requisito do parágrafo único do art. 42 que tem que estar presente para se afastar a condenação à devolução em dobro.

Fica, pois, determinada a devolução de valores na forma dobrada.

No tocante ao pedido de reparação por dano moral, tenho que a pretensão não merece acolhida. Isso porque, em que pese as possíveis irregularidades na contratação, a autora não tentou resolver a questão administrativamente.

Cumprе ressaltar que o dano moral, consiste na lesão aos direitos da personalidade, como a vida e a integridade corporal. A requerente não demonstrou nos autos qualquer tipo de ofensa à honra, que pudesse configurar um ressarcimento a título de dano moral.

No caso, caberia à autora demonstrar uma situação humilhante ou similar, capaz de demonstrar um efetivo abalo moral, trazendo extremo sofrimento psicológico, o que

não foi feito.

Para que se configure o dano moral indenizável, a dor, o sofrimento, a tristeza, o aborrecimento impingidos devem ser tais que, fugindo à normalidade, interfiram no comportamento e no bem estar psíquicos do indivíduo. Isto porque o dano moral se origina de ofensa a um direito de personalidade, como ressaltado.

De outra parte, o mero aborrecimento não é capaz de gerar abalo moral indenizável, pois se trata de uma situação cotidiana que todo indivíduo enfrenta, sendo novamente relevante anotar a inércia da autora em buscar solução administrativa da questão, como aduzido. Assim, eventual prejuízo da demandante é tão somente de ordem material, que está sendo reparado com a determinação de restituição dos valores descontados.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confira-se:

"AÇÃO DE CONDENÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS.

Desconto indevido em benefício previdenciário. Parcial procedência. Insurgência do autor. Órgão responsável pelo pagamento de benefício previdenciário. Pleito de reconhecimento de solidariedade passiva pelo desconto indevido. Postulante que desistiu do pedido quanto à referida autarquia. Homologação por sentença. Não conhecimento. Dano moral. Inocorrência. Não obstante o caráter alimentar atribuído ao benefício previdenciário, a hipótese retratada nos autos se caracteriza como mero aborrecimento, sem o potencial de causar danos à honra e à imagem do autor. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA". (TJSP - Apelação Cível nº 1001064-07.2018.8.26.0484 - Relator Des. Sebastião Flávio - Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 27/02/2019) (destaques não originais)

"Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência parcial - Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora Ilícito caracterizado - Devolução na forma simples é o que se impõe, pois ausente a comprovação de má-fé - Danos morais inexistentes - Dissabor que não supera o mero aborrecimento - Sentença mantida - Recurso não provido". (TJSP - Apelação Cível nº 1005351-35.2018.8.26.0024 - Relator Des. Marcia Dalla Déa Barone - Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 28/05/2012) (destaques não originais)

"SEGURO DE VIDA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTOR QUE NEGA A CONTRATAÇÃO - DESCONTO MENSAL INDEVIDO - RESTITUIÇÃO. Contrato de seguro de vida que teria sido efetuado pelo autor, mas que não foi reconhecido - ele - Instituição financeira que não comprova a autenticidade por da assinatura constante no pacto - Desconto mensal indevido, sendo de rigor a restituição do montante debitado da conta corrente - DANOS MORAIS - Não configuração do dano moral alegado, porquanto o caso concreto se apresenta como mero aborrecimento - Inexistência de apontamento valor junto ao SERASA e SPC - Danos morais não caracterizados - Indenização descabida - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso improvido." (TJ-SP-AC: 10088279520158260506 SP 1008827 95.2015.8.26.0506, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 05/04/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2019) (destaques não originais)

Assim, diante do entendimento já firmado pelo Tribunal de Justiça, inexistente dano moral a se reconhecer pelo fato de não haver qualquer comprovação da efetiva ocorrência de uma situação capaz de o gerar, existindo, ao revés, uma situação de mero aborrecimento da vida cotidiana.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar inexigível a obrigação que deu origem aos descontos descritos na inicial;

b) condenar o réu a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados da autor relativo ao contrato de empréstimo ora reconhecido como inexigível, sob nº 5182264436617, com incidência de correção monetária pela Tabela Prática de Cálculos

Judiciais divulgada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir da data de cada desconto indevido, com juros de mora na razão de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, a autora deverá devolver o réu o valor de R\$ 554,57, com incidência de correção monetária pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais divulgada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data do crédito.

Os valores devidos por ambas as partes serão apurados em fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculos aritméticos, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem (art. 368, do Código Civil).

Em virtude da sucumbência parcial recíproca, cada parte arcará com metade das despesas processuais.

Ainda, condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte contrária que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o proveito econômico obtido pela autora com a presente demanda, consistente no valor total do débito (aqui considerado o número de parcelas a vencer multiplicado pelo valor mensal de cada prestação) somado ao valor que a presente sentença determinou que seja restituído à requerente.

Por outro lado, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte ré que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo réu com a presente demanda, consistente na diferença entre o valor total pretendido pela autora (que corresponde ao valor atribuído à causa) e o valor que o réu está sendo condenado a devolver. Contudo, a cobrança em relação à autora fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita, a teor do disposto no art. 98, § 3º, do CPC, conforme decisão de fls. 20.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos definitivamente com as cautelas de estilo.

Publique-se e Intimem-se.

Assis, 29 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA